

1501657-34.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... ao delito de associação para o tráfico de drogas e deferida liberdade provisória condicionada em relação ao crime de tráfico (fls. 70/72).

Conforme procedimento especial, notificados, os Réus apresentaram defesas preliminares, nas quais pugnaram por absolvição sumária. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 14/07/22 (fls. 259/260), sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501657-34.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501657-34.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INGRID ANDRADE DOS REIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de INGRID ANDRADE DOS REIS e outro, denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2020, por volta de 17h45', na passagem Vinte e Nove de Abril, nº 163, bairro Piraporinha, nesta Comarca de Diadema, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam adquirido, mantido em depósito e guardado, para consumo de terceiros, 200 porções de cocaína em pó (185 g) e 5 porções de cannabis sativa L (4 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denunciada foi presa em flagrante delito, mas foi relaxada essa custódia em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas e deferida liberdade provisória condicionada em relação ao crime de tráfico (fls. 70/72).

Conforme procedimento especial, notificados, os Réus apresentaram defesas preliminares, nas quais pugnaram por absolvição sumária. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 14/07/22 (fls. 259/260), sendo certificadas as citações positivas.

Em audiência, tomaram-se os interrogatórios e foram ouvidas testemunhas. Encerrada a instrução, as partes formularam alegações finais orais (mídia digital).

É o relatório do necessário.

Fundamento e passo a decidir.

Preliminarmente, reiteram-se os fundamentos das decisões que indeferiram os

requerimentos formulados pela defesa em audiência, bem como afasta-se arguida nulidade por violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Isso porque o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal dispõe expressamente que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” - grifos nossos. Desta forma, a garantia fundamental não é absoluta e não pode ser arguida com o fito único de utilização de uma garantia constitucional como manto de imunidade para a prática de crimes, uma vez presente a hipótese excepcional prevista pelo constituinte originário e observado princípio da proporcionalidade. Logo, uma vez caracterizada a situação da flagrância de delito equiparado a hediondo, mostrava-se desnecessária autorização judicial para o ingresso dos policiais no imóvel. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

"NULIDADE - Indeferimento do pedido de reconstituição dos fatos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Diligência requerida desnecessária para o deslinde da causa. Alegação de nulidade da busca e apreensão porque realizada com violação de domicílio. Afastamento. Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito. Preliminares rejeitadas. TRÁFICO DE DROGAS - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Desclassificação para o delito do artigo 28. Inadmissibilidade. Conjunto probatório consistente. Penas e regime carcerário corretamente fixados. Sentença mantida. Apelação desprovida." (TJSP; Apelação 0006923-18.2016.8.26.0637; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).

"Apelação da defesa - tráfico - preliminar quanto à ilegalidade do flagrante - violação de domicílio - tráfico de drogas, delito de caráter permanente - preliminar de nulidade em razão de inobservância a procedimento previsto em lei - lei especial tem primazia sobre lei de caráter geral - preliminar de nulidade em razão da não intimação da defesa para a realização de audiência no Juízo deprecado - intimada a defesa quanto à expedição da carta precatória, tornando desnecessária nova intimação da data designada para a realização das audiências no Juízo deprecado - preliminares afastadas (...)" (TJSP; Apelação 0007418-27.2014.8.26.0348; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).

"Habeas corpus - Paciente denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nulidade - Auto de prisão em flagrante - Violação de domicílio - Não ocorrência - A prisão em flagrante delito do paciente ocorreu na forma do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Ilicitude das provas obtidas pelos policiais que realizaram o flagrante do acusado - Inadmissibilidade - Validade probatória - Descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Alegado cerceamento ao direito de defesa do paciente (...) Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus 2001443-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).

Ainda preliminarmente, sem dúvida, é corolário do direito fundamental à privacidade e intimidade o resguardo da inviolabilidade das comunicações e de seus dados, assegurada no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República. Assim, o sigilo das comunicações garante a faculdade que toda pessoa tem de restringir os destinatários de seus atos comunicativos, vetando, dessa forma, a intromissão indesejada dos demais em sua privacidade e intimidade, sem a sua permissão. Por tais motivos é que a interceptação das comunicações telefônicas exige prévia ordem judicial de fins persecutórios, assim como os dados de comunicação telefônica, que indiquem frequência e destinatário das comunicações da pessoa ("régua"), por traduzirem um padrão, um hábito do interlocutor, também estão acobertados pelo sigilo, exigindo-se, igualmente, prévia ordem judicial.

Dados avanços tecnológicos, que ampliaram os meios e os canais de comunicação, o legislador ordinário faz expressa referência à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Neste passo, a Lei nº 12.965/2014, Marco Civil da Internet, estabeleceu garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e, no art. 7º, inciso II, proclamou direito de inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações por meio da internet, cuja quebra somente seria permitida por meio de ordem judicial.

Por tais razões, a jurisprudência de nossos Tribunais, desde o paradigmático julgamento do RHC 51.531/RO pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tem entendido pela indispensabilidade de prévia autorização judicial para o acesso aos dados de telefonia móvel, ainda que o aparelho celular que os contenha tenha sido apreendido no âmbito de prisões em flagrante, sob pena de violação aos direitos fundamentais à intimidade e privacidade e, assim, com consequente ilicitude probatória.

Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACESSO A DADOS CONTIDOS NO CELULAR DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares - envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. 2. No caso, por ocasião da própria prisão em flagrante - sem, portanto, a prévia e necessária autorização judicial -, o policial atendeu o telefone do réu e afirmou que a ligação tratava de um pedido de venda de substância entorpecente. Na delegacia o celular do réu foi apreendido, desbloqueado e nele verificada a existência de mensagens de texto que indicavam prévia negociação da venda de entorpecentes, sem, portanto, anterior autorização judicial. 3. A denúncia se apoiou em elementos obtidos a partir da apreensão do celular pela autoridade policial, os quais estão reconhecidamente contaminados pela forma ilícita de sua colheita. Não é possível identificar, com precisão, se houve algum elemento informativo produzido por fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável, porquanto o contexto da abordagem do ora recorrente, aliado à quantidade de drogas apreendidas e aos dados obtidos por meio do acesso ao celular do agente, é que formaram a convicção do Parquet pelo oferecimento de denúncia pela possível prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso ao celular do recorrente, bem como de todas as que delas decorreram e, consequentemente, anular o Processo n. 0000377-09.2016.8.26.0196 ab initio, sem prejuízo de oferecimento de nova denúncia, desde que amparada em elementos informativos regularmente obtidos. Em consequência, fica determinado o relaxamento da prisão cautelar imposta ao réu, por excesso de prazo. (STJ, HC 542.293/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) - grifos nossos.

“Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Decretação da prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Convergência de aspectos subjetivos favoráveis. Ilicitude probatória. Liminar indeferida. 1. Alegação de prova ilícita. Quebra de sigilo de dados de telefonia móvel desprovida de prévia autorização judicial. Acesso às informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente. Inexistência de elementos que permitam a afirmação da ilicitude probatória. Acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos que teria sido precedido de autorização judicial em observância ao entendimento jurisprudencial afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Impossibilidade de reconhecimento da ilicitude através da via estreita do habeas corpus. Necessidade de exame aprofundado das provas que se mostra incompatível na presente via. 2. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema. 3. Fumus comissi

delicti. Elementos colhidos na fase preliminar de investigação que sustentam a viabilidade da imputação inicial e o juízo de admissibilidade que se seguiu. 4. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Crime praticado mediante grave ameaça e violência. Declaração precisa da vítima acerca das agressões sofridas. Gravidade que extrapola a simples adequação penal típica. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2266523-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022) - grifos nossos.

Na espécie, tem-se requisição ministerial e atendimento dessa requisição pela i. Autoridade policial, sem, contudo, ter sido decretada judicialmente a quebra do sigilo telefônico da ré, motivo pelo qual, nos termos da legislação e jurisprudência retro, DECLARA-SE NULA a prova produzida com base no acesso aos dados telefônicos da ré sem prévia ordem judicial, que em nada inclinou as demais provas produzidas neste processo penal, inclusive por ausente hipótese descoberta fortuita de provas. Por tais motivos, não será considerada o laudo pericial de fls. prova válida

No mérito, é procedente a pretensão punitiva.

Com efeito, a materialidade do delito foi bem demonstrada pela juntada do auto de exibição e apreensão de fls. 11, do auto de constatação de fls. 13/15 e pelo encarte do laudo químico-toxicológico de fls. 172/174, donde constata-se serem as substâncias apreendidas drogas, que geram dependência química e psíquica, sem haver autorização legal bastante para legitimação da conduta. A coautoria delitiva é igualmente certa, o que se extrai claramente da apreensão de documento pessoal do réu no lugar do crime e da prova oral coligida.

Inicialmente, verifica-se ter sido a ré presa em flagrante delito, mantendo em depósito referidas drogas. E, apesar do auto de prisão em flagrante delito ser uma providência de ordem administrativa, a cargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que evidencia de proêmio não só a autoria, mas também a materialidade, de modo que o conjunto probatório, como um todo, inicia-se fortalecido. Já prelecionava Júlio Frabrini Mirabete:

"A palavra 'flagrante' é derivada do latim, flagrare (queimar) e flagrans, flagrantis (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminoso e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria" (Processo Penal, Ed. Atlas, pág. 356) - grifos nossos.

Na sequência, sob o manto do contraditório, o auto de prisão em flagrante delito foi no todo corroborado por outros elementos de prova, notadamente pelos dizeres dos responsáveis pela captura e condução do preso, ratificados de forma firme e coesa em Juízo.

Segundo as TESTEMUNHAS narraram em sede policial (fls. 02/05) e ratificaram em Juízo, elas teriam recebido notícia anônima de que o imóvel no lugar do crime seria utilizado como depósito de drogas a serem distribuídas em pontos de venda aos usuários, tanto na comunidade Tamarutaca, em Santo André, quanto na comunidade da Coca, nesta Comarca de Diadema. Em diligência no lugar do crime, os policiais teriam realizado campana, em viatura descaracterizada, por cerca de 1h.

Nesse período de campana, os policiais civis teriam observado os réus saírem juntos daquela residência, aparentemente sem nada trazerem consigo. Após 15', a ré teria retornado para a via dos fatos e os policiais teriam se dirigido à ela. Percebendo que seria por eles abordada, a denunciada não teria adentrado na residência. Assim, ela teria sido parada pelos policiais cerca de 5 metros à diante e, em busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado com ela.

Informalmente questionada, a ré teria confessado aos policiais que residia naquele local com o denunciado, onde armazenavam as drogas e de onde ela as transportaria, ocultadas em suas vezes, até os pontos de venda, onde o réu distribuiria as porções. A denunciada perceberia R\$ 100,00 por dia de traficância, motivada por necessidades econômicas. Somente naquela data, eles teriam recebido 1.000 porções de cocaína de manhã e, em oito transportes, já teriam distribuído 800 delas, permanecendo em depósito 200 porções de cocaína na residência dos acusados, lugar do crime.

Nesse contexto, os policiais teriam ingressado na residência e localizado, ao lado da cama dos denunciados, lugar apontando pela ré, as 200 porções de cocaína, em embalagens idênticas, mais 5 porções de skunk, espécie mais concentrada de maconha. No local, os policiais ainda teriam apreendido uma carteira de trabalho do acusado. Por fim, a denunciada teria relatado que a contabilidade da traficância ficaria registrada no aparelho celular dela, então apreendido.

Somente a denunciada teria sido presa em flagrante delito, sendo encaminhada às medidas de estilo. O acusado não teria se feito presente em qualquer momento da prisão em flagrante e não teria sido localizado nas imediações, sequer nos dias seguintes para ele prestar declarações. Não teria sido apreendido dinheiro. Não haveria instrumentos de partição e embalagens de drogas no local. As testemunhas desconheciam os acusados.

A denunciada teria facultado a entrada dos policiais na residência dela e entreguelhes o aparelho celular dela, voluntariamente. César recordava-se da própria acusada ter exibido as conversas dela no telefone com Carlos para os policiais, no lugar do crime e na Delegacia.

Por sua vez, a acusada INGRID silenciou em seu interrogatório policial (fls. 06).

Em Juízo, qualificou-se como pessoa de 27 anos de idade, manicure, que auferiria cerca de R\$ 1.050,00 por mês, em média. Não seria usuária de drogas. Teria mãe, irmãos e duas filhas. Não teria sido processado anteriormente. Assumiu ser distribuidora das drogas apreendidas, há oito dias, mediante paga de R\$ 100,00 por dia. Contudo, exonerou Carlos de qualquer ligação com as drogas apreendidas. Segundo a acusada, ela namoraria o réu há pouco mais de um mês e ele não moraria na casa dela. Somente haveria a CTPS dele na residência dela, mas não moraria no lugar do crime. Naquele local, residiriam apenas a interroganda e suas duas filhas. O denunciado não teria conhecimento do tráfico de drogas pela denunciada, mesmo sendo encontradas as drogas ao lado da cama dela, em uma sacola à vista de qualquer pessoa que frequentasse o local.

Para o mais, a acusada imputou aos policiais diversas ilegalidades quando da prisão dela. Consoante interrogatório judicial, a denunciada teria sido abordada na via pública, os policiais teriam levantado a blusa dela e retirado o aparelho celular da cintura dela. Já teria sido recolhida na viatura, onde os policiais teriam exigido que ela desbloqueasse o aparelho celular.

A denunciada negou ter autorizado o ingresso dos policiais na residência dela. Eles teriam adentrado no domicílio enquanto da interroganda ainda estava na viatura. Somente tempos depois ela teria sido levada ao apartamento, onde estariam os policiais e um vizinho. Na sequência, ela teria sido conduzida à Depol, onde os policiais teriam algemado até mesmo as pernas dela, por pura e imotivada raiva da acusada. Nesse local os policiais teriam voltado a olhar o celular da acusada sem autorização dela. Desconhecera os policiais responsáveis por sua prisão.

Enfim, o acusado CARLOS não foi encontrado em solo policial (fls. 91/92). Sob contraditório, qualificou-se como pessoa de 22 anos de idade, teria diversas atividades econômicas, que auferiria cerca de R\$ 1.250,00 por mês, em média. Não seria usuário de drogas. Teria mãe e irmãos. Já teria sido processado anteriormente por tráfico de drogas e, quando menor, teria respondido por roubo, furto, tráfico e porte de arma. Negou a coautoria do crime.

Alegou conhecer Ingrid há cerca de um mês e dormir na casa dela. Porém, não dormiria na casa dela e não teria conhecimento da posse de drogas por parte dela. Nunca teria reparado em sacola ao lado da cama da corré. Andaria sempre com seus documentos pessoais e somente naquela data teria esquecido a CTPS dele no local. Desconhecera as testemunhas policiais. Teria ligado para a corré logo após a

prisão dela e um dos policiais teria atendido o celular dela e ameaçado o réu. O denunciado teria bloqueado esse canal e não teria comparecido na Depol.

Ora, diante do eloquente conteúdo probatório amealhado pela acusação, bem como diante da ausência de qualquer prova sobre suspeição da palavra das testemunhas e sem que elas tivessem qualquer interesse em falsear para prejudicar pessoas que elas sequer conheciam, os interrogatórios judiciais mostram-se absolutamente inverossímeis e isoladas, sendo, verdadeiramente, utilizados somente para buscar livrar o corréu Carlos da responsabilidade penal que lhe cabe.

Sem dúvida, para além da ausência de qualquer suspeição sobre os testemunhos prestados nestes autos, a bem de ver-se, mostra-se absolutamente inverossímil que o réu tenha esquecido documento pessoal, que habitualmente não é portado pelo homem médio (CTPS), na residência de pessoa que ele alegou conhecer há um mês. Ainda, menos verossímil ainda é a versão dos réus no sentido de que o acusado teria dormido no local e não teria ele sequer visto uma sacola cheia de drogas no assoalho do lado da cama da corré.

Com efeito, os interrogatórios são pueris e não convencem.

Logo, diante desse contexto probatório, não devem ser acolhidas as teses defensivas, pois os testemunhos dos policiais estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, incluindo a apreensão da CTPS do acusado no lugar do crime, além das provas periciais, sem haver demonstração necessária de que testemunhas teriam interesse em prejudicar os acusados, sem nenhum motivo relevante.

Ademais, em sendo as testemunhas agentes do Estado, as provas produzidas pela acusação não podem ser desqualificadas apenas por essa circunstância. Ao revés, certamente, gozam de presunção de legitimidade, não havendo o mínimo indício de que testemunhas teriam agido fora dos mandamentos de seus cargos. Neste diapasão, pertinente colacionar a vasta jurisprudência dos Tribunais, consolidada sobre essa questão:

"Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa da natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las." (TJSP, Apel. 017371-87.2011.8.26.0050, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, data do julgamento 13/12/2012, v.u.) – grifos nossos.

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Procedência. Recurso da defesa. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena mantida.

Antecedentes desabonadores que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06. Regime inicial fechado

adequadamente imposto. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Mairinque; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 06/03/2017) – grifos nossos.

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ, HC 166979/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, dje 15/08/2012).

Por tais razões, as versões apresentadas em Juízo pelos Réus restam isoladas nos autos, sem qualquer elemento que desabone os depoimentos firmes e coesos das testemunhas e ausentes quaisquer outros testemunhos que os infirmem, sendo, portanto, inexistente no caso concreto qualquer flagrante forjado em desfavor de Carlos, ao passo que, quanto à Ingrid a defesa cingiu-se à atribuir ilícitos aos policiais, sem apresentar qualquer prova que pudesse levar à inocência dela.

Ao seu tempo, à luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, há fatores concretos que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo dos agentes dirigiu-se especificamente à mercancia - e não ao consumo pessoal -, tais como: as naturezas e a diversidade de drogas (cocaína e maconha); a quantidade (205 porções) de drogas apreendidas; o local da apreensão, notoriamente lugar habitual de tráfico

de drogas; as condições de acomodamento das drogas (divididas em porções e com embalagens idênticas).

Outrossim, conquanto o Réu Carlos não seja primário (fls. 276/277), não faz jus ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Todavia, na esteira dos testemunhos dos policiais, a ré Ingrid não seria a integrante de organização criminosa, sendo esse membro o acusado, que inclusive a teria aliciado para a prática odiosa. Assim, verifica-se que ela tinha atividade habitual lícita outra e que os próprios policiais afirmaram que ela não seria membro de organização criminosa, de modo que tem direito ao reconhecimento de privilégio.

Nada obstante, a quantidade de drogas apreendidas (205 porções delas) recomendam essa diminuição no seu patamar médio, via critério jurisprudencial cuja legitimidade vem sendo reconhecida em todos os Tribunais. Nesse sentido:

"(...) Ocorre, porém, que o Plenário deste Supremo Tribunal, em julgamento recente do HC nº 112.776/MS e do HC nº 109.193/MG, ambos da relatoria do Ministro Teori Zavascki, (julgados em 19/12/13 - acórdãos ainda não publicados), firmou orientação no sentido de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas com um condenado por tráfico de entorpecentes podem ser usadas, na fase da dosimetria da pena, tanto na primeira como na terceira etapas do cálculo; contudo, jamais de forma cumulativa. (...)" (STF, HC 120146 / SP - SÃO PAULO, Julgamento: 22/04/2014, Órgão Julgador: Primeira Turma) - grifos nossos.

"O Tribunal a quo aplicou a causa de diminuição de pena (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a natureza, diversidade e quantidade de droga apreendida 4 invólucros de maconha, pesando 13,3g (treze vírgula três gramas), 26 de cocaína, pesando 21g (vinte e um gramas) e 35 de crack, pesando 9g. - O acórdão está de acordo com o entendimento desta Corte de que o juiz, na aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, deve levar em consideração a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes: AgRg no HC 247.019/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 25.3.2013; HC 221.761/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 14/06/2013). - Estando devidamente fundamentado o quantum de redução da pena, é inviável, em sede de habeas corpus, a sua alteração, tendo em vista a necessidade de revolvimento de fatos e provas. Precedente: HC 173.511/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 22.2.2012." (STJ, HC 259.490/RJ, 6ª Turma, DJe 18.06.2014) - grifos nossos.

"(...) Na interpretação do referido redutor deve o juiz atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o objetivo legal foi de beneficiar com a sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento. (...)" (TJSP, 0000993-76.2015.8.26.0597, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/02/2017; Data de registro: 13/02/2017) - grifos nossos.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, assaz hábeis a arrimar o presente édito condenatório, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, a dosimetria das penas.

Em primeira fase: observado o art. 42 da Lei 11.343/06, preponderantes a natureza (cocaína é droga mais nociva para a saúde do que as demais listadas, notoriamente, assim violando-se com mais gravidade o objeto jurídico tutelado pela norma penal incriminadora) e a quantidade (205 porções) das drogas apreendidas. Observe-se que a quantidade das drogas não será tomada em desfavor da Condenada Ingrid, por já ser considerada na terceira fase de dosimetria quanto à ela. Por essas razões, em primeira fase, fixam-se as penas-bases com aumento de 1/8 para Ingrid e de 1/7 para Carlos.

Em segunda fase: concorre circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de Ingrid, tendo em vista a assunção completa da conduta e não apenas para defesa, mas em colaboração com a descoberta da verdade real, quando realizada

informalmente. Por tais motivos, suas penas tornam ao patamar mínimo. Concorre agravante da reincidência específica em desfavor de Carlos (fls. 276/277), motivo do aumento das suas penas na proporção de 1/5 - e não somente em 1/6, praxe deste Juízo para reincidência simples e genérica, observados princípios da individualização e da proporcionalidade das penas.

Em terceira fase: concorre causa de diminuição da pena para a condenada Ingrid, relativa ao tráfico privilegiado, de maneira que as penas dela são reduzidas na proporção de 1/2, como supra fundamentado. Não há causas de aumento das penas. Logo, tornam-se as penas definitivas em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa para Ingrid, bem como em 6 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 685 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Atenta às diretrizes dos art. 33 do Código Penal, à equiparação do crime tráfico aos hediondos pelo próprio constituinte, diante das circunstâncias judiciais preponderantes, desfavoráveis, tal como acima sublinhadas, bem como diante da quantidade da pena aplicada e da reincidência específica de Carlos, fixo como adequado regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o aberto para Ingrid e fechado para Carlos, por entender serem os necessários e suficientes para a reprovação e para a prevenção do crime praticado por cada Condenado, conforme o princípio da individualização das penas.

Registra-se, no ponto, a extrema gravidade com que o crime foi praticado, intranquilizando a comunidade local a permanência dos Condenados em regime outro que não o fechado - e não sem razão, ante a possibilidade concreta do cometimento de outros delitos semelhantes, dado reiterado envolvimento dos Condenados com drogas.

Quanto à Ingrid, observados os requisitos legais postos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, por não se mostrar recomendável em face das circunstâncias judiciais concretas acima sublinhadas, deixo de deferir aos Condenados a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. Neste sentido, mantém-se a jurisprudência de nossos tribunais:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) Apelo da defesa. Regime prisional mais brando para início do cumprimento da pena - impossibilidade - declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da lei de crimes hediondos - sem efeito erga omnes - modalidade menos severa para o cumprimento da pena mostra-se insuficiente e inadequada à repressão dos delitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - inviabilidade - apelante que não preenche aos requisitos estabelecidos no art. 44, III, do Código Penal, em especial a culpabilidade do agente e a sua conduta social a indicar a inaplicabilidade da referida benesse. Apelo ministerial. Fixação do regime fechado - possibilidade - regime mais rigoroso adequado ao caso em tela, diante da gravidade concreta do delito. (...) Recurso da defesa desprovido e provido o ministerial." (TJSP, 0025599-53.2015.8.26.0506, Relator(a): Ivana David; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de registro: 06/03/2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório, como formulado na denúncia, , nos moldes do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez reconhecidos os Réus como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, para:

CONDENAR a ré INGRID ANDRADE DOS REIS ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem prejuízo do cumprimento da pena de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente;
CONDENAR o réu CARLOS DANIEL DA SILVA ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do cumprimento da pena de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato,

corrigido monetariamente.

Não custodiados no curso do processo, os Condenados poderão exercer o direito de recorrer em liberdade, ausentes causas supervenientes para prisões preventivas, como tem-se compreendido na jurisprudência.

Finalmente, os condenados deverão suportar custas e despesas processuais, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Transitada em julgado a presente, expeçam-se as comunicações necessárias e anote-se o quanto baste.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.R.C.

Diadema, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA